

1501964-51.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... a organização e associação dos réus para o narcotráfico.

Tal panorama subsume-se ao suporte fático do artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADES DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CARACTERIZADOS OS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501964-51.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501964-51.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALBERTO DOS SANTOS NETO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

TIAGO SANTANA DE SÁ e ALBERTO DOS SANTOS NETO foram denunciados por incursão no caput do art. 33 e no caput do art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 31 de agosto de 2021, no período da manhã, na Rua Teresa Cruz Augusta, 306 - Jardim Mauá, nesta cidade de Mauá, os denunciados guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, drogas ilícitas descritas auto de exibição e apreensão de fls. 39-40 e laudo de constatação de fls. 42-4, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar os denunciados associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 196 e 206) e apresentaram

respostas à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas e os réus interrogados.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto as Defesas buscam, em síntese, a absolvição, o reconhecimento da coação moral irresistível, em relação ao réu Tiago, ou, ao menos, a fixação das penas no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão e o tráfico privilegiado, sob regime penitenciário inicial aberto e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletins de ocorrência (fls. 03-9), autos de exibição e apreensão (fls. 39-40 e 47), fotografias de fls. 45-6, laudo de constatação (fls. 42-4), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 282-4), laudo da balança apreendida (fls. 285-7) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, Tiago permaneceu em silêncio (fl. 15). Sob o contraditório, afirmou que estava guardando uma bolsa para um agiota, de quem pegou dinheiro emprestado. Tinha ciência de que havia entorpecente na bolsa. Esclareceu que este agiota o estava ameaçando há meses, por não conseguir pagar os juros. Em razão disso, pediu para guardar essa bolsa em troca do perdão da dívida. A princípio negou esse pedido, porém devido às constantes ameaças aceitou a oferta. Segundo o agiota, ele deveria guardar a bolsa (sic) "até segunda ordem". Em relação ao corréu Alberto, afirmou que ele somente foi até a sua residência buscar o documento de um carro que vendeu para ele. Alegou que os policiais não encontraram nada no veículo de Alberto e confirmou ter autorizado os policiais a ingressarem na sua residência (mídia digital).

O réu Alberto, por sua vez, perante a Autoridade Policial, negou a prática do delito, alegando que (sic) "foi abordado e trazido a esta delegacia e só aqui soube que havia um monte de droga apreendida, sob a alegação que estavam e sua posse e de seu amigo Tiago. Disse que esteve no local apenas para buscar o documento de um carro e nisso foi abordado" (fl. 27). Em juízo, manteve a negativa, dizendo que apenas foi até o local pegar o recibo de um carro que comprou de Tiago. Negou ter saído da residência com um saco de lixo com as drogas. Afirmou que não conseguiu pegar o recibo naquele dia, em razão da prisão, mas pegou depois (mídia digital).

A versão dos réus é pífia.

Os policiais civis, na fase administrativa, historiaram que (sic) "receberam informação de que um indivíduo jovem de cor branca, olhos claros, estatura mediana, morador de uma casa situada na rua Dona Tereza Cruz Augusta, entre os números 228 a 320, jardim Mauá, nesta cidade, estaria vendendo maconha "no atacado". O depoente e sua parceira por cerca de um mês em dias e horários alternados monitoraram o local a fim de identificar a residência e o indivíduo, porém durante esse período não perceberam nenhuma movimentação suspeita nem conseguiram identificar o suposto traficante nem o imóvel, que fica em uma área estritamente residencial sem nenhuma "biqueira" nas imediações. Ocorre que hoje, por volta das 07h30, foram informados que aquele indivíduo iria realizar uma venda de grande quantidade de maconha naquele endereço. Diante de tal informação, o depoente e sua parceira imediatamente

rumaram para o local e montaram campanha na rua Dona Tereza Cruz Augusta, próximo ao numeral 200, quando, por volta das 08h50, avistaram um veículo Honda/City, cor cinza, placa FIA-6698/SP, estacionar na frente da residência nº 306, ocasião em que um indivíduo de cor parda, trajando moletom com capuz, desceu do veículo e ingressou na referida residência. Segundo o depoente, depois de aproximadamente vinte minutos aquele indivíduo de cor parda trajando moletom com capuz saiu da residência nº 306 trazendo consigo um saco de lixo preto volumoso e o colocou no banco do passageiro dianteiro do veículo Honda/City, e junto daquele indivíduo também saiu da residência um rapaz de cor branca e eles conversaram brevemente na calçada enquanto o indivíduo de cor parda entrava no veículo. Diante de tal situação suspeita, abordaram rapidamente os indivíduos, que não ofereceram qualquer resistência e se identificaram como Alberto dos Santos Neto, indivíduo de cor parda que estava no veículo, e Tiago Santana de Sá, indivíduo de cor branca que estava na calçada da residência nº 306, e ao revista-los encontraram apenas seus telefones celulares marcas Motorola e Iphone, respectivamente. Em seguida realizaram uma busca no veículo e imediatamente sentiram forte odor de maconha e ao abrir o saco de lixo preto que estava sobre o assoalho dianteiro direito do carro encontraram dez (10) tijolos de maconha envoltos em fita adesiva preta. Indagaram os dois indivíduos acerca da droga encontrada no veículo e se havia mais drogas no imóvel e eles responderam "vamos conversar" e Tiago lhes disse ainda que havia mais drogas na sua casa. O depoente e sua parceira ingressaram no imóvel nº 306 e já avistaram no chão da lavanderia mais 50 (cinquenta) tijolos com odor característico de maconha embalado semelhantemente àqueles encontrados no veículo e uma pequena balança digital, porém nada de ilícito encontraram nos outros cômodos do imóvel. O depoente afirma que não encontraram nenhum valor em dinheiro com os indivíduos nem na casa e os questionaram acerca do pagamento dos 10 (dez) tijolos de maconha e Tiago lhe respondeu que realizou a venda para Alberto pagar quando ele revendesse a droga" (fls. 10-3).

Durante a instrução, o policial civil Flávio reiterou integralmente a dinâmica dos fatos e acrescentou que Tiago franqueou a entrada da equipe na residência. Explicou que não conseguiram apurar a destinação do entorpecente encontrado com Alberto, entretanto, Tiago confirmou ter entregado a droga para Alberto revender. Questionado pelo Defensor Público, afirmou que naquele dia foi a primeira vez que viu Alberto. Não soube informar há quanto tempo os réus se conheciam. Questionado pelo Defensor constituído, disse que o local não é um ponto de venda de drogas, ao contrário, é uma área estritamente residencial. Esclareceu que a denúncia não foi anônima, mas não podia expor todos os detalhes sobre sua investigação. Reafirmou que não existia mandado de busca, mas Tiago franqueou voluntariamente a entrada dos policiais na residência. A esposa do réu Tiago estava dormindo no quarto da casa e, durante a ocorrência, foi-lhe explicado o que estava acontecendo. Neste momento, Tiago dizia que ela não sabia o que ele fazia. Explicou que os 10 tijolos de maconha foram encontrados dentro de um saco de lixo preto que estava no interior do veículo, enquanto os demais tijolos foram apreendidos no chão da casa. Logo que entraram na residência visualizaram as drogas e uma balança digital. Acrescentou que após as denúncias esta foi a única abordagem realizada, pois além do numeral da residência ser compatível com o informado, visualizaram movimentação suspeita do veículo de Alberto, com emplacamento de São Paulo, inclusive. Esclareceu que foram feitas duas denúncias, sendo que na primeira fizeram campana durante um mês, mas nada de suspeito foi visualizado (mídia digital).

A policial civil Ivonete reiterou as declarações do seu colega de farda. Ratificou que o réu Tiago autorizou a entrada da equipe na residência. Questionada pelo Defensor constituído, afirmou que ao realizar a busca na residência, questionaram Tiago sobre o dinheiro, oportunidade em que ele disse ter entregado as drogas ao Alberto, em confiança, para pagamento após a revenda. Disse que foram feitas duas denúncias, a primeira, que desencadeou uma campana que perdurou um mês, porém, sem sucesso, e, a outra, culminou na prisão em flagrante dos suspeitos. Durante as campanas anteriores nenhuma outra pessoa foi abordada, pois era uma rua residencial

e não visualizaram nada suspeito (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

A testemunha de defesa, Jessica Caroline Ferreira da Silva, em juízo, afirmou que não tem parentesco com o réu Tiago e é apenas amiga dele. Disse que Tiago é comerciante em Ribeirão Pires e pegou dinheiro emprestado com um rapaz para abrir uma loja. Depois soube que este homem passou a ameaçar o réu. Somente o réu Tiago foi ameaçado (mídia digital).

Ao final da instrução, de rigor a condenação.

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente os réus.

De outro lado, as versões apresentadas pelos réus restaram isoladas, sem comprovação mínima do alegado.

O depoimento da testemunha de defesa Jessica Caroline Ferreira da Silva, "amiga" do réu, deve ser visto com ressalvas e, por si só, não infirma a prova acusativa.

Anote-se, neste ponto, que consta no inquérito policial que o nome da companheira de Tiago seria "Jessica" (fl. 15) e "Jessica Caroline da Silva" seria a pessoa responsável pelos cuidados dos filhos do réu (fl. 17). Assim, ao que tudo indica, a testemunha de defesa ouvida em juízo não seria apenas uma amiga do réu como informado.

Descabida a alegação da Defensoria Pública quanto à ilegalidade na busca pessoal, pois os policiais civis que realizaram a abordagem afirmaram que, após denúncia sobre uma suposta venda de grande quantidade de drogas no local, visualizaram o réu Alberto chegando na residência de Tiago, onde permaneceu por aproximadamente meia hora, e saindo com um saco de lixo volumoso, na companhia daquele, de forma que demonstradas as fundadas razões para a busca pessoal.

No mais, a enorme quantidade de maconha encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a forma em que estava acondicionada e a balança apreendida trazem elementos suficientes de que os réus tinham as drogas para entrega a terceiros.

Do mesmo modo, há vários dados, somados à quantidade de droga apreendida,

comprovando que os réus mantinham conduta estável, com divisão de tarefas, a indicar a associação para o narcotráfico e não mero concurso de agentes.

Segundo o apurado, havia divisão de funções, Tiago guardava o entorpecente em sua residência para a venda no "atacado", enquanto Alberto era responsável por revender o entorpecente. A estabilidade é evidente diante da relação de confiança existente entre os acusados, tanto que Alberto pegou os 10 tijolos de maconha de Tiago para pagamento a prazo, após a revenda. Tudo isso, em consonância com as denúncias e informações obtidas pelos policiais civis, comprova a organização e associação dos réus para o narcotráfico.

Tal panorama subsume-se ao suporte fático do artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADES DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CARACTERIZADOS OS ELEMENTOS TIPIFICANTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. [...] 5. Encontra-se suficientemente demonstrada nos autos a prévia combinação de vontades entre, pelo menos, o paciente e uma corré, de caráter duradouro e estável, necessária e suficiente para configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido, em parte." (STF HC 109.708/SP 2ª T. Rel. Min. Teori Zavascki j. 23.06.2015 DJE 03.08.2015).

Ainda:

"É que, a experiência assim está a demonstrar, os criminosos não criam, formalmente, pessoas jurídicas para essa finalidade, não lavram, por óbvio, contratos de associação, a afastar qualquer possibilidade de comprovação documental da reclamada associação. Por outra mão, nem sempre se terá nos autos interceptação telefônica prévia, haja vista que, no mais das vezes, esse tipo de prova só costuma ser produzido, palmar, com a prévia e necessária autorização judicial, quando se está diante de uma associação criminosa para fins narcotraficantes com contornos um pouco mais robustos. No entanto, no dia-a-dia, no comum dos casos, os agentes criminosos associam-se e o fazem em associações que não chegam a ter contornos que chamam a atenção, ao menos em um primeiro momento, das Polícias, Civil ou Militar, mesmo das Guardas Civis. Daí a importância de uma análise meticulosa do que se trouxe aos autos, desde a fase inquisitorial até a fase judicial, a se esperar que, nesta, o obtido anteriormente encontre conforto mínimo a propiciar substrato probatório suficiente para o proferimento de uma sentença condenatória, em 1ª Instância, ou da sua manutenção, em 2ª Instância. E via de regra, está a experiência a revelar que a prova que se encontra à disposição do Magistrado é a de comportas indiciárias, tão maltratada, gratuita e graciosamente, por parte não só da Doutrina, como também da Jurisprudência; como se os indícios não fossem, como são, provas robustas o bastante para sustentar, com folga, a condenação deste ou daquele criminoso enovelado no crime de associação para o narcotráfico." (TJ-SP, Apelação nº 0003469-11.2013.8.26.0451, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Cumpra registrar que Alberto está preso preventivamente pela suposta prática de outro delito relacionado ao tráfico de drogas (fls. 255-6).

No mais, descabida a alegação da Defesa quanto ao reconhecimento da excludente de culpabilidade fundada na coação moral irresistível, pois nada existe de concreto a comprovar que o réu Tiago praticava o tráfico contra sua vontade, compelido pela ameaça de um suposto terceiro. A simples alegação do réu, corroborada única e exclusivamente pelo testemunho de uma "amiga", não basta para caracterizar uma

situação de coação moral irresistível, que reclama sempre uma prova robusta (JUTACRIM 99/146, 49/384, RT 813/596). Cabe ter em mente que constitui ônus da defesa a prova da existência de fato que exclua a antijuridicidade ou a culpabilidade do réu - ao menos de uma situação de verossimilhança -, no termos do artigo 156 do Código de Processo Penal (TJSP, AP 1500162-98.2020.8.26.0557, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 9.11.20).

Dessa forma, entendo que os delitos estão fartamente comprovados.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos réus, em relação ao crime de tráfico de drogas, 1/3 acima do mínimo legal, em razão da exacerbada quantidade de maconha apreendida - 60 tijolos (29,1 kg) -, fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa. Para o crime de associação para o tráfico, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, ou seja, 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Sobre o aumento nesta etapa, em caso análogo, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

"Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do Código Penal, e do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-base de cada réu em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos e 08 meses de reclusão, e 660 dias-multa. Justificou a exasperação com a expressiva quantidade de drogas apreendidas (15,1 quilos de maconha), consignando entendimento jurisprudencial do C. STF nesse sentido (RHC111.440/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.05.2012). Reputo justificada a exasperação adotada nesta fase. A quantidade de drogas é expressiva, e há amparo legal para tanto, no artigo 42, da lei de Drogas" (TJSP; Apelação Criminal 1501838-57.2019.8.26.0544; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Conforme exposto acima, afasta-se a incidência da atuante prevista na alínea "c" do inciso III do art. 65 do Código Penal.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, parcial e não espontânea, para o réu Tiago, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, em poder de enorme quantidade de entorpecentes, e buscou falsear a verdade, isentando o corréu de responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Quanto ao pleito da Defensoria Pública, em favor do réu Alberto, verifica-se que o acusado não confessou a prática delitiva.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra: 'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da

atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.).

Apelação criminal – Tráfico de drogas – [...] Dosimetria – pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se

verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).

Na última fase, não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tratando-se de réus associados para a prática do tráfico. Sobre o tema, recentes decisões do c. Superior Tribunal de Justiça:

"A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes." (AgRg no HC 667.959/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

"Tendo sido o Réu condenado pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação do Agravante às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas." (AgRg no HC 729.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Por fim, diante do concurso material entre os delitos, somam-se as penas que totalizam 09 anos e 08 meses de reclusão e 1.366 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica dos réus.

Deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, notadamente pelo quantum de pena fixado.

Pela mesma razão não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis, insuficientes para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR os réus TIAGO SANTANA DE SÁ e ALBERTO DOS SANTOS NETO, qualificados nos autos, a cumprir pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.366 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 e no caput do art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Faculta-se aos réus o apelo em liberdade, diante da liminar concedida em habeas corpus (fls. 139-42 e 194).

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas (fls. 39-40), nos termos do art. 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Em relação aos demais objetos apreendidos (fls. 39-40 e 47), nos termos dos artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, aguarde-se eventual provocação do interessado no prazo de 90 dias do trânsito em julgado, desde que comprovada a propriedade. Decorrido o prazo, sem manifestação, determino o perdimento do bem, para posterior leilão ou destruição, se o caso.

No tocante ao veículo, oficie-se ao pátio para informações quanto ao estado de conservação ou eventual leilão realizado. Com a resposta, dê-se vista ao Ministério Público.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita aos réus.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA